

1500811-56.2021.8.26.0160

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Carlos Alves de Melo

Comarca: Descalvado

Foro: Foro de Descalvado

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... ser considerada como instrumento de combate ao tráfico de drogas. Nesse sentido cabe citar trecho do Acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do Colégio Recursal de Santos (Apelação nº 1502560-71.2018.8.26.0562): "Outro argumento frequentemente trazido nos debates sobre a criminalização do porte para consumo diz respeito à inibição ao tráfico de drogas pela lógica de que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Descalvado

Foro de Descalvado

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Luciano Esteves, s/n, Descalvado - SP - cep 13690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500811-56.2021.8.26.0160 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500811-56.2021.8.26.0160

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Murilo Ibanez Nogueira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Carlos Alves de Melo

Vistos.

Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Murilo Ibanez Nogueira. Narra a denúncia que, 23/05/2020, o réu trazia entorpecente para consumo pessoal, sem autorização legal, incidindo nas penas do art. 28, da lei 11.343/06.

Designada audiência para transação penal, realizada em 08/02/2022 (fl. 36), o réu deixou de comparecer, embora estivesse intimado (fl. 33). O Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 41/42) e foi determinada a intimação do réu para oferecer resposta à acusação (fls. 43/44).

Citado à fl. 63, sobreveio resposta à acusação às fls. 68/73.

É o breve relatório.

A pretensão acusatória deve ser rejeitada.

Revendo meu entendimento anterior sobre a matéria, entendo que o fato descrito na denúncia é atípico.

Embora o E. Supremo Tribunal Federal ainda não tenha concluído o julgamento do RE 635.659, entendo, na linha do que consta das manifestações dos Ministros Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin, que o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06 é incompatível com a Constituição Federal. Conforme constou do voto do Relator: "criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desnecessariamente, o direito ao livre

desenvolvimento da personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional".

A respeito do tipo penal em análise, dispõe a Lei nº 11.343/ 06:

"Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo."

O Direito Penal, tendo em vista a natureza das sanções que aplica em caso de descumprimento das normas, deve necessariamente observar os princípios da legalidade, subsidiariedade, fragmentariedade, intervenção mínima, exclusiva proteção de bens jurídicos e lesividade. Conforme dispõe o princípio da lesividade, as condutas criminalizadas devem representar um dano ou perigo concreto ao bem jurídico.

Quanto ao tipo penal em questão, argumenta-se que a criminalização da conduta de quem porta drogas para uso pessoal visa tutelar: 1) a saúde do usuário; 2) a saúde pública.

A primeira finalidade, ou seja, tutela da saúde do usuário de drogas, não parece ser constitucional, pois invade indevidamente a esfera da intimidade e autonomia do próprio indivíduo, com ofensa direta ao art. 5º, X, da CF, sem que haja qualquer proteção a bens jurídicos de terceiros. Como ressalta Pierpaolo Bottini, "a proteção de um bem jurídico não pode passar pela criminalização de seu próprio titular. A incidência da sanção penal sobre alguém retira uma parcela de sua autodeterminação, em operação apenas autorizada para assegurar um patamar de dignidade de terceiros, afetado pelo crime. Não parece fazer qualquer sentido a subtração da liberdade de alguém com o objetivo de proteger esta mesma liberdade sob outro prisma". (1 Disponível em ).

Verifica-se que o tipo penal em questão viola o princípio da ofensividade, pois a conduta do usuário de drogas diz respeito apenas à sua esfera individual, sem que haja lesão à ordem jurídica. O Estado não pode, através do Direito Penal, interferir no modo de agir ou de ser do indivíduo, criminalizando uma conduta que diz respeito apenas à sua saúde.

Cabe ressaltar que a criminalização da referida conduta sequer pode ser considerada como instrumento de combate ao tráfico de drogas. Nesse sentido cabe citar trecho do Acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do Colégio Recursal de Santos (Apelação nº 1502560-71.2018.8.26.0562): "Outro argumento frequentemente trazido nos debates sobre a criminalização do porte para consumo diz respeito à inibição ao tráfico de drogas pela lógica de que o consumo alimenta o tráfico, o que se prestaria a proteger a saúde pública. Ora, o usuário de drogas não tem qualquer controle sobre o comportamento do traficante. E, ainda que se admita a possibilidade do usuário evitar o consumo de drogas o que não é verdadeiro em inúmeros casos impossível atribuir a ele o controle ou a condução do comportamento doloso do comerciante de drogas. A aplicação da pena com essa motivação seria punir alguém pelo ato do outro. Uma punição fundada na incapacidade do Estado de controlar o verdadeiro comportamento danoso. Em suma, aplica-se a sanção no usuário diante da dificuldade de encontrar, investigar e condenar o verdadeiro culpado no sentido dogmático pela violação à saúde pública: o comerciante de produtos ilícitos. A Constituição Federal, ao determinar ao legislador o combate ao tráfico de drogas (CF, artigo 5º, XLIII), não conferiu carta branca para o uso de qualquer

estratégia de política criminal, mas apenas aquelas que não conflitem com outros princípios do mesmo texto legal.”

Dessa forma, também não há ofensa à saúde pública, pois a quantidade de drogas apreendidas no caso concreto não é suficiente para circular e colocar em risco a saúde de terceiros. A pequena quantidade apreendida com o investigado é destinada apenas ao seu rápido consumo, ou seja, o único atingido é o próprio usuário.

Portanto, o tipo penal em questão é inconstitucional, pois criminaliza condutas que geram apenas autolesão da própria saúde, sem dano ou mesmo perigo concreto a qualquer pessoa, salvo o próprio usuário.

Nesse sentido há decisões dos Colégios Recursais do Estado de São Paulo:

“EMENTA: Recurso de Apelação. Posse de entorpecentes para consumo pessoal. Rejeição da denúncia pelo Juiz do Juizado Especial Criminal com fundamento na inconstitucionalidade do tipo penal e na atipicidade material da conduta. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, uma vez que a quantidade de drogas apreendida é pequena, suficiente apenas para consumo imediato, sem chance de circulação e de afetação da saúde pública. Embora esteja verificada a subsunção da conduta praticada pelo denunciado ao tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, a conduta imputada na denúncia não é relevante o suficiente para abalar o bem jurídico tutelado pela norma, o que afasta o interesse de agir do Estado. Ainda que se trate de delito de perigo abstrato, é indispensável demonstrar a aptidão da quantidade de droga apreendida para produzir danos à saúde pública, o que se dá, no caso, com a apreensão de drogas em quantidade suficiente para, teoricamente, circular e colocar em risco a saúde pública. Com efeito, a quantidade de drogas encontrada em poder do agente deve ser suficiente para colocar em risco a saúde pública, o que se dá com uma quantidade que extrapola o possível de ser consumido imediatamente pelo usuário. Se o sujeito tem droga insuscetível de ser imediatamente consumida, teoricamente essa droga pode circular, como, por exemplo, mediante furto ou esquecimento, e cair em mãos erradas. Nesse caso, há lesão à saúde pública. Do contrário, uma pequena porção suficiente apenas para uso imediato, o único atingido é o próprio indivíduo. Se não há possibilidade de lesão à saúde pública, a criminalização da conduta é ilegítima. Conforme preciosa lição de John Stuart Mill, no clássico livro "Sobre a liberdade", "o único propósito com o qual se legitima o exercício do poder sobre algum membro de uma comunidade civilizada contra a sua vontade é impedir dano a outrem" e "cada qual é o guardião conveniente da própria saúde, quer corporal, quer mental e espiritual. Os homens têm mais a ganhar suportando que os outros vivam como bem lhes parece do que os obrigando a viver como bem parece ao resto". Recurso conhecido e desprovido.” (Apelação Criminal nº 1500052-35.2020.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, j. 15/03/2022);

“CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Inconstitucionalidade. Violação aos art. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, VI e X, CF. Tipo penal que não possui bem jurídico subjacente, interferindo indevidamente na esfera de autonomia privada e intimidade. Tipo penal carente de lesividade, regra a fundamentar a aplicação da lei penal. Inconstitucionalidade declarada em controle difuso de constitucionalidade. RECURSO PROVIDO para absolver o acusado, nos termos do art. 386, III, do CPP. (Apelação Criminal nº 1501672-68.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, 1ª Turma Criminal, j. 25/03/2022).

Ademais, conforme consta do voto proferido pelo Relator da Apelação nº 1500052-35.2020.8.26.0352 acima citada, o ajuizamento de uma ação penal gera gastos consideráveis, com a nomeação de defensor dativo para a defesa do réu, diligências com oficiais de justiça, além das horas de trabalho de juízes, promotores,

servidores para, ao final, eventual condenação pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não gerar qualquer efeito prático, pois até mesmo a reincidência é afastada segundo entendimento dos Tribunais Superiores (STF. 2ª Turma. RHC 178512 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/3/2022; REsp 1672654/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

Diante do exposto, sendo o art. 28 da Lei 11.343/06 inconstitucional, ABSOLVO Murilo Ibanez Nogueira, com fundamento no art. 386, inc. III do Código de Processo Penal.

Fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, conforme art. 72 da Lei de Drogas, assim como a restituição ao investigado de bens apreendidos no inquérito policial.

Ciência ao Ministério Público.

Ciência à Defensora nomeada.

Após o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações de praxe, expeça-se certidão de honorários no patamar máximo da tabela do Convênio DPE-OAB e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se.

Descalvado, 20/06/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA